

1508800-17.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... seja, autoriza a desclassificação.

Não se pode presumir o tráfico tão só porque, segundo os guardas, aquele bairro tinha ocorrência de tráfico.

A suspeita ou indícios não são razoáveis para se convencer do tráfico, não presumido porque a quantidade, repete-se, não era também excessiva.

A abordagem, em verdade, foi casual, recomendada por suspeita, mas sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508800-17.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508800-17.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238927/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 27138366 - 04º D.P.

AMERICANA, 2238927 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUDEIA DE SANTANA RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

JUDEIA DE SANTANA RIBEIRO está sendo processada como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput' da Lei 11.343/06, acusada de no dia 31 de agosto de 2022, por volta de 17h14, na Avenida Bandeirantes, 01, Centro, nesta cidade, guardar, com a finalidade de tráfico, 37 porções de crack, substâncias que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Teria sido localizado ainda, com a ré, o valor de cento e quarenta e dois reais.

Recebida a denúncia em 27 de outubro de 2022, fls. 145/146, a ré foi citada.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se Defesa e a Acusação.

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e

ao final, foi a ré interrogada.

Sem mais requerimentos, em memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 190/191).

A Defesa, em preliminar, pleiteia a complementação do laudo. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06. A revista, bem como a prisão feita por Guarda Municipal, seriam ilegais. A ré seria usuária e a droga seria para o seu uso. Não foram encontrados petrechos. O suposto usuário ouvido na fase policial não foi encontrado na fase judicial. A ré informou a origem do dinheiro. Alternativamente, a desclassificação para o artigo 33, §3º da Lei 11.343/06. A ré negou o tráfico. Era moradora de rua e usaria a droga com outros moradores de rua. Em caso de condenação, requer pena mínima, regime brando, detração penal e recurso em liberdade (fls. 197/217).

É o relatório.

DECIDO.

Não é caso de complementação de laudo, provada a materialidade da infração oportunamente, pelo auto de exibição e apreensão, bem como exame químico toxicológico e que atestou se tratar, a substância, de droga.

Inclusive, a pedido da própria Defesa, ouviu-se a experta, que bem explicou a forma como foi detectada a natureza entorpecente da substância, nos moldes da legislação de drogas, tendo até mesmo refeito o exame e confirmada a conclusão.

Rejeito semelhante preliminar.

Por igual, não vinga a alegação de nulidade pela atuação da guarda civil municipal, com revista.

A qualquer do povo é dada a prisão em flagrante, em especial aos guardas civis, que estavam no exercício regular de função, conforme relato, com patrulhamento em praça pública.

Na jurisprudência recente do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL Ação Penal Preliminar Alegação de nulidade da prisão em flagrante efetuada por integrantes da guarda municipal Inocorrência Qualquer pessoa, no exercício da cidadania, pode efetuar prisão em flagrante Dicção do art. 301 do Código de Processo Penal Conquanto a guarda municipal não esteja investida de atividade de polícia preventiva, pode atuar em caráter secundário na pacificação social, prevenção e inibição da prática delitiva, mormente quando ocorrida em locais e condições que estão sob sua esfera de proteção Inteligência do art. 5º, incisos III, IV, V, XIV e XVI, da Lei nº 13.022/2014 Preliminar afastada Apelação Criminal nº 1502519-56.2021.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 26 de outubro de 2022. XISTO RANGEL Relator(a).

De ver que no particular não ocorreram diligências típicas de polícia, como busca domiciliar ou quebra de dados telemáticos, mas de realização de prisão em flagrante, ainda assim quando os servidores públicos municipais desempenhavam função regular, de patrulhamento em vias da cidade e praça pública.

Até mesmo no C. STF, onde há repercussão geral a respeito do tema instalada (ainda não concluída - EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÕES DE GUARDA CIVIL METROPOLITANA. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES E ALCANCE DA RESERVA LEGAL CONTIDA NO ART. 144, § 8ª, DA LEI MAIOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS E SEGUROS PARA NORTEAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO E DE ALCANCE GERAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA), em recente voto vencedor do Ministro Luiz Roberto Barroso (que reconheceu ilegalidade na atuação investigativa de guarda civil), foi por ele enfatizado:

“...A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança

Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida." A G .REG. NOS EMB .DECL. NO A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.281.774 SÃO PAULO RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO 0 Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública de São Paulo, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido da absolvição do ora agravante, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, que negava provimento ao agravo. Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.6.2022 a 10.6.2022.

A questão, pois, está muito distante do que genericamente se procura atribuir como nulidade na atuação da Guarda Civil Municipal, o que se espera seja definido na repercussão geral referida.

Sem embargo, há de se distinguir situações, relembrando que o caso dos autos se refere a prisão em flagrante por guarda civil municipal e não de diligências pretéritas e ao depois consumação de prisão em flagrante.

Pelo que se depreende dos autos, a ré estava em situação que exigia intervenção dos agentes da autoridade, que resultou na apreensão de droga.

Havia indicativo de ocorrência de crime, em tese, que é permanente (tráfico) para a realização da prisão em flagrante (não para a busca ou revista, como é a hipótese) assim, sofre atenuação pelo interesse coletivo em se apurar, prevenir e punir a prática de crime.

A abordagem não foi gratuita ou ocasional, mas movida por patrulhamento preventivo. De lembrar, também, que estando o agente de autoridade no regular exercício da função preventiva, exatamente para proteção do coletivo, não carece de mandado para abordar e revistar, segundo o critério da discricionariedade imediata que lhe confere o Estado para cumprir o mister.

Bem daí a regra do artigo 244 do Código de Processo Penal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Apenas provado despropósito na ação profissional desenvolvida, o que não ocorreu e foi produzido em termos de prova, pode dar ensejo à nulidade perseguida pela Defesa.

Incontroverso, também, que o policiamento preventivo e a revista imediatamente realizada resultaram em apreensão de drogas.

Não se tratou de busca investigativa, quando o objetivo estatal, por meio de seus agentes, é relacionar a pessoa abordada a crime ocorrido, exigindo-se então a fundada suspeita a legitimar a ação.

Diversamente, como é o caso destes autos, a busca preventiva se dirige a fundada suspeita, portanto, funciona como garantia de que a pessoa não será, aleatoriamente, relacionada à prática de uma infração penal investigada, sem possuir relação com o fato. Já a busca preventiva visa manter a ordem pública, evitar ilícitos, dar efetividade às leis e se dirige a todos, indistintamente. Exigir fundada suspeita sem distinguir a finalidade da ação estatal é desconsiderar texto legal vigente, além de inverter a consideração de presunção de legitimidade dos atos realizados pela administração pública e seus agentes, para considerá-la em regra abusiva.

No mérito a denúncia é parcialmente procedente.

Na fase extrajudicial, a ré negou a traficância. Alegou que a droga seria para uso compartilhado e sem finalidade de lucro. O dinheiro apreendido seria resultado de atuar como 'garota de programa' (fls. 06).

Em Juízo, repetiu que tinha feito um programa, Luís estava junto e foi ao local com colegas. Iria pegar 'kit' de pedras para usar. Quando foi entregar o dinheiro para o traficante ocorreu a abordagem. Não teve tempo de entregar esse dinheiro. Não foi traficar. Era usuária. Todas as pessoas que estavam com ela também eram usuárias. Fumavam juntas. Moravam na rua e se encontravam para consumir drogas.

A versão não foi infirmada com a segurança necessária pela prova oral.

O guarda civil Alan Fernandes relatou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Viram a ré, o Luís e mais cinco pessoas conversando e decidiram abordar. Na revista, nada foi encontrado com as cinco pessoas, as quais foram liberadas.

Com o Luís, foi encontrada uma porção de crack e com a ré Judeia uma latinha de bala com 37 porções de crack. Na sua cintura, ela teria a quantia de cento e quarenta e dois reais, que retirou e entregou para a equipe. Questionados, a ré alegou que a droga seria para o seu consumo e o dinheiro seria fruto de prostituição. O Luiz disse ter comprado aquela pedra da ré, pelo valor de dez reais. O motivo da abordagem da ré foi por estar em local conhecido como ponto de venda de drogas. As pessoas que lá estavam afirmaram ser usuárias.

Seu colega de farda, Marcos César Ferreira, reiterou a versão. Estavam em patrulhamento pela Avenida Bandeirantes e avistaram a ré e o Luís em um lugar já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Foram abordados e o Luiz estava de posse de uma porção de crack em sua mão. Ao ser indagado, ele afirmou teria acabado de comprar da ré, pelo valor de dez reais. A ré Judeia segurava uma latinha de bala, com 37 porções de crack. No seu shorts, no elástico, tinha o valor de cento e quarenta e dois reais, que ela retirou e entregou para a equipe. Ela alegou ser usuária e que o dinheiro seria proveniente de um "programa" que tinha realizado.

A testemunha de defesa Ingrid Lopes Barbosa alegou que para o teste rápido de constatação foi utilizada a metodologia do teste colorimétrico, que é um teste presuntivo que indica a possibilidade da presença de cocaína. O Instituto Criminalista costuma se basear no grupo Internacional SWG-DRUG, que preconiza todas as metodologias que podem utilizar; tanto para testes presuntivos como para testes definitivos, baseados nas suas categorias. Para o teste presuntivo utilizam o teste de categoria menos específica e para testes definitivos, que são feitos posteriormente, são testes que dão mais certeza do conteúdo. Confirma que o teste químico de cromatografia em camada delgada oferece 100% de confiabilidade. Ele é considerado um teste de categoria "B" e não tem falso positivo para cocaína. A metodologia internacional exige que sejam feitos dois testes de categoria "B" e mais um "C". Por isso, realizam a cromatografia em camada delgada em dois sistemas diferentes. Ela permite que se utilize fase móvel e revelador diferentes, que interagem de forma diferentes com as moléculas, podendo assim confirmar utilizando dois "B" e uma "C".

É possível realizar um teste complementar com a contraprova. Recentemente realizou a cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas, técnica "A" e confirmou o resultado.

Bem certo e provado, assim, de forma convincente, de que a ré era responsável pelas drogas apreendidas, até porque não ousou negar essa propriedade, no interrogatório judicial.

Não obstante, duvidosa a ocorrência do tráfico.

A ré foi vista em atividade rotineira da guarda civil municipal e acabou abordada. Em sua mão, mantinha uma latinha com 37 porções de "crack" (10g - fls. 12) e um valor em dinheiro.

A ré negou o tráfico e alegou que foi ao local adquirir drogas. Sobre a origem do dinheiro alegou teria sido de "programa" que teria realizado.

A quantidade da droga apreendida, 37 porções, pesando quantia não expressiva (10 g), são insuficientes para concluir se destinassem ao tráfico, especialmente porque o alegado comprador, Luís, não foi ouvido sob o crivo do contraditório.

Os guardas não se referiram a qualquer informação pretérita implicando a ré com o

tráfico, na ocasião, assim como fizeram abordagem por suspeita de infração, o que restou confirmado pela apreensão das drogas.

Não seria impossível ou improvável que a ré estivesse adquirindo, ausentes outras diligências (reforce-se), mas a dúvida, mínima que seja, autoriza a desclassificação.

Não se pode presumir o tráfico tão só porque, segundo os guardas, aquele bairro tinha ocorrência de tráfico.

A suspeita ou indícios não são razoáveis para se convencer do tráfico, não presumido porque a quantidade, repete-se, não era também excessiva.

A abordagem, em verdade, foi casual, recomendada por suspeita, mas sem qualquer informação pretérita comprometendo a ré.

A dúvida, mormente envolvendo grave crime, volve em favor da acusada, recomendando, como requerido alternativamente pela Defesa, a desclassificação para crime outro, do artigo 28 da Lei de Drogas.

Vale dizer, quando a imputação não rompe a esfera da mera possibilidade ou probabilidade, a dúvida é suficiente para a absolvição ou, como na espécie, para o reconhecimento da figura do artigo 28 da Lei de Tóxicos, uma vez que o entorpecente existe e foi apreendido em poder do réu.

Esse o entendimento que vem sendo adotado na jurisprudência:

“TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 104/106).

Por isso de rigor a condenação, com a observação de necessidade de se desclassificar o crime para porte de drogas.

Fixação das penas.

A ré possui antecedentes (fls. 57), o que será considerado na estipulação das medidas previstas na Lei de Drogas.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra JUDEIA DE SANTANA RIBEIRO, condenando-o à pena de advertência, medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, prestação de serviços à comunidade, pelo período de dois (02) meses, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Para a prestação de serviço imposta por infração à Lei de Drogas, atente-se para o que dispõe o artigo 28, par. 5º da Lei 11.343/2006.

Revogo eventuais medidas cautelares impostas se concedido benefício processual, intimando-se.

Isento a ré das custas.

Não há elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Sem vinculação o numerário apreendido com o tráfico, bem como eventual objeto, defiro a sua liberação à ré, após o trânsito em julgado, expedindo-se o necessário. Audiência de advertência a ser designada oportunamente.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se a nome da ré no rol dos culpados.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Presa preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo reclusa, pela desclassificação, expeça-se alvará de soltura.

PIC.

Americana, 08 de dezembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA